

1002846-09.2022.8.26.0452

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... decidiu a Corte Superior que "o roubo de talonário de cheques durante o transporte por empresa contratada pelo banco não constituiu causa excludente da sua responsabilidade, pois se trata de caso fortuito interno. Se o banco envia talões de cheques para seus clientes por intermédio de empresa terceirizada deve assumir todos os riscos com tal atividade". Acrescentou o STJ nesse caso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

2ª Vara

Praça Joaquim Antonio de Arruda, 126, Piraju - SP - cep 18800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002846-09.2022.8.26.0452 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002846-09.2022.8.26.0452

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Orlando Wolf

Requerido:

Banco Pan S/A

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

ORLANDO WOLF propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS em face do BANCO PAN S.A, alegando que a instituição financeira ré efetuou descontos em seu benefício de aposentadoria, a título de empréstimo consignado (contrato nº 335855497-4), no valor mensal de R\$ 64,90, o qual nunca contratou; que o valor do suposto empréstimo nunca foi depositado em sua conta. Nessa conformidade, requereu a concessão da justiça gratuita, a tutela de urgência para suspender os descontos, a devolução em dobro dos valores já descontados, com a respectiva declaração de inexistência dos negócios jurídicos subjacentes, e a condenação do demandado ao pagamento de danos morais no importe de R\$ 10.000,00. Juntou procuração e documentos (fls. 12/19).

Foi deferida a gratuidade da justiça e indeferida a tutela de urgência (fls. 20/21).

Devidamente citado (fl. 25), o requerido apresentou contestação intempestiva (fls. 35, 39/45 e 75).

O autor interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido, acolhendo a tutela de urgência pleiteada (fls. 71/74).

Houve réplica (fls. 86/93).

É o relatório. Fundamento e decido.

Julgo o processo no estado em que se encontra, nos moldes do art. 355, I, do CPC, porque reputo suficientes os documentos aportados aos autos para o desate da matéria controvertida, sendo desnecessária dilação probatória.

Devidamente citado (conforme AR de fl. 25), o réu deixou escoar in albis o prazo para apresentar contestação (consoante certificado à fl. 35), apresentando-a intempestivamente (fl. 75), de sorte que decreto a sua revelia, com fulcro no artigo 344 do CPC.

A demanda procede em parte.

A prestação de serviços bancários se dá no mercado de consumo, mediante remuneração, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto nos arts. 2º, 3º, caput e § 2º, e 17, todos deste diploma legal.

No regime do CDC, a fornecedora-ré responde objetivamente pelos danos causados por fato do serviço (art. 14). Sob a lente da teoria objetiva, arrimada no risco da atividade e independente da concorrência de culpa, a falha é presumida ope legis. O fornecedor só não será responsabilizado se provar: (i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

Embora o CDC não contemple expressamente o caso fortuito e a força maior, tais eventos imprevisíveis e inevitáveis, positivados no art. 393 do CC, também figuram como excludentes da responsabilidade civil no sistema consumerista, já que constituem fatores obstativos gerais do nexo de causalidade. O fundamental é perquirir se esses acontecimentos escaparam à esfera de vigilância do fornecedor, levando ao rompimento do liame de implicação recíproca entre a conduta deste e os danos sofridos pelo consumidor, sendo imperativo distinguir, nesse mister, o fortuito interno do fortuito externo. Nos dizeres de FLÁVIO TARTUCE:

Opino que a conclusão deve levar em conta a relação que o fato tido como imprevisível ou inevitável tem com o fornecimento do produto ou a prestação de serviço, ou seja, com o chamado risco do empreendimento, tão caro aos italianos. O debate traz à tona aquela antiga diferenciação entre fortuito interno e fortuito externo, bem desenvolvida, entre os clássicos, por Agostinho Alvim. O primeiro – fortuito interno – é aquele que tem relação com o negócio desenvolvido, não excluindo a responsabilização civil. O segundo – fortuito externo – é totalmente estranho ou alheio ao negócio, excluindo o dever de indenizar. Conforme enunciado doutrinário aprovado na V Jornada de Direito Civil, evento de 2011, “O caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida” (Enunciado n. 443).

Em outras palavras, deve-se atentar para os riscos que envolvem a atividade a partir da ideia de proveito ao vulnerável da relação estabelecida. Como bem aponta Anderson Schreiber, “a conclusão acerca da incidência ou não da teoria do fortuito interno parece, antes, vinculada a um juízo valorativo acerca de quem deve suportar o ônus representado por certo dano. Reconhece-se certo fato como inevitável, mas se entende que tal fatalidade não deve ser suportada pela vítima. Daí a aplicação da teoria do fortuito interno ser mais intensa no campo da responsabilidade objetiva, onde é de praxe atribuir ao responsável certos riscos que, embora não tenham sido

causados pela sua atividade em si, não devem recair tampouco sobre a vítima". (Manual de direito do consumidor: direito material e processual, volume único / Flávio Tartuce, Daniel Amorim Assumpção Neves - 9. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 204).

Em suma: apenas excluirá a responsabilidade do fornecedor o fortuito externo, equiparável à força maior, evento não relacionado com a prestação do serviço, que era impossível de ser evitado, dentro do seu poder de controle.

Particularmente com relação aos serviços prestados pelas instituições financeiras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou a compreensão de que a fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias configura caso fortuito interno (Súmula nº 479), que faz parte dos serviços prestados pelas instituições financeiras - isto é, está atada aos riscos da atuação do fornecedor -, inapto a excluir a responsabilidade das fornecedoras de tais comodidades. Como anota ALEXANDRE DARTANHAN DE MELLO GUERRA:

(...) Afirmou o STJ em outra oportunidade que "há responsabilidade da instituição bancária atrelada ao risco da própria atividade econômica que exerce pela entrega de talão de cheques a terceiro que, mediante fraude, abriu conta bancária em nome do recorrido, dando causa, com isso e com a devolução do cheque emitido por falta de fundos, à indevida inclusão do nome do autor em órgão de restrição ao crédito", o que, diz, revela o caso fortuito interno. No mesmo sentido, decidiu a Corte Superior que "o roubo de talonário de cheques durante o transporte por empresa contratada pelo banco não constituiu causa excludente da sua responsabilidade, pois se trata de caso fortuito interno. Se o banco envia talões de cheques para seus clientes por intermédio de empresa terceirizada deve assumir todos os riscos com tal atividade". Acrescentou o STJ nesse caso que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC". (Reflexões de Magistrados Paulistas nos 25 Anos do Código de Defesa do Consumidor, coordenação: Alexandre Dartanhan de Mello Guerra e Alexandre David Malfatti. São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2015, pp. 254/255).

Na espécie, o autor alega que não contratou o empréstimo consignado firmado com a parte ré. Daí os pleitos de declaração de inexistência dos débitos e de condenação do réu à devolução dobrada dos descontos, além de reparação por danos morais.

A parte ré, de seu turno, sustenta a regularidade das contratações, acostando, intempestivamente, o suposto instrumento contratual firmado (fls. 56/62). Sucede que o autor afirma que não efetuou a assinatura ali aposta.

Em julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por meio de perícia ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369) (REsp nº 1.846.649-MA, Segunda Seção, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.06.2021, Tema nº 1.061). Até porque não se pode imputar à parte demandante o ônus de demonstrar cabalmente que não firmou contrato com o demandado, prova de fato absolutamente negativo. Tocava, assim, à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, a lastrear os débitos exigidos, encargo do qual não se desincumbiu.

Emerge dos autos, então, que houve contratação fraudulenta em nome do demandante, por pessoa diversa daquela que realmente pactuou os negócios jurídicos. Desconhecido o verdadeiro responsável pela inautenticidade, avulta a inexistência do negócio jurídico, por falta de um dos elementos essenciais de seu suporte fático, qual seja, a manifestação de vontade livre e desembaraçada (consentimento

válido). Afinal, “partindo do pressuposto de que o ato jurídico é a ato lícito de vontade, esta, naturalmente, constitui o substrato daquele, e as regras a seguir estatuídas são uma decorrência lógica de tal posição original.” (SILVIO RODRIGUES, Dos vícios do consentimento, 3ª edição, São Paulo, Editora Saraiva, 1989, pp. 9/10). Segue-se que o negócio jurídico é inválido e, por extensão, inidôneo a produzir qualquer efeito jurídico, na esteira da lição de ARNALDO RIZZARDO:

A não validade tem um campo bem amplo, decorrente de toda série de infringências ao ato ou negócio jurídico. Com fidelidade apreendeu Francisco Amaral o sentido: “Negócio jurídico inválido é o que não vale para o direito, por não preencher os requisitos legais, não se lhe reconhecendo o poder de produzir as relações jurídicas pretendidas. Consiste na medida jurídica que traduz não só uma sanção do sistema legal para o descumprimento da norma jurídica pertinente à formação do negócio, como também, e principalmente, um julgamento, um juízo de valor acerca da conveniência da própria existência e eficácia da declaração da vontade”. A invalidade atinge todos os males que afetam o ato ou negócio, desde a falta de suporte inicial, até a não coadunação à forma ordenada na lei. Não se restringe à ausência de capacidade dos figurantes, ou à ilicitude, à impossibilidade do objeto, dentre outros fatores, mas abarca exigibilidades mais primárias, como a inexistência do próprio objeto contratado, ou da parte falsamente colocada como presente.

Num sentido bem apropriado, acentua Emílio Betti que “a invalidade é aquela falta de idoneidade para produzir, por forma duradoura e irremovível, os efeitos essenciais do tipo..., que provém da lógica correlação estabelecida entre requisitos e efeitos, no mecanismo da norma jurídica, e é, ao mesmo tempo, sanção do ônus imposto à autonomia privada de escolher meios idôneos para atingir os seus escopos de regulamentação dos interesses”.

É, pois, a invalidade o gênero de todas as modalidades de conceitos que não confortam os atos ou negócios praticados pelas partes.

Nesta dimensão, se ausente um dos elementos necessários para a constituição, como uma das partes, ou o objeto, diz-se inválido por inexistente o negócio. Impossível, v.g., tratar-se de um divórcio se os envolvidos não são casados, ou se alguém buscar alimentos em favor de uma pessoa se nenhum grau de parentesco for encontrado entre o pretendente a alimentos e o sedizente obrigado. É inexistente o negócio que obriga a prestar alimentos, e, por consequência, não traz eficácia. De sorte que a ineficácia está ligada à inexistência. Já a nulidade está afeta à falta de um dos requisitos colocados para a validade, como a capacidade. Não se confunde com a ausência da parte, que levaria à inexistência, mas ao não preenchimento dos requisitos para ser parte, como a capacidade. Por outro lado, se a parte é capaz, mas seu consentimento restou viciado pelo erro, ou dolo, ou coação, o negócio é anulável.

Em resumo, inclui-se na invalidade toda sorte de causas que afeta o negócio, seja por inexistência, não produzindo efeitos, seja por falta de um dos requisitos elencados para o seu reconhecimento, ou seja por defeitos na sua origem.

Inexistentes se denominam os negócios quando carecem não de um requisito, mas de um elemento essencial, como do preço na compra e venda, ou do objeto, por ter já ocorrido uma venda anterior envolvendo o mesmo bem. Inexiste o negócio ante a falta de elemento essencial para a mera constituição. Como pretender uma rescisão de um contrato de compra e venda se não existiu o consenso sobre o preço? Inadmissível, ainda, a ação de reintegração de posse de um imóvel dado em comodato se esta figura não restou delineada.

Bem evidente a lição de Cunha Gonçalves: “A inexistência legal consiste em faltar a um ato qualquer elemento essencial à sua existência jurídica ou à sua formação, de

sorte que, sem esse elemento, tal ato não se pode conceber, é ato embrionário, simples aparência". José de Abreu Filho, em *O Negócio Jurídico e sua Teoria Geral*, 4ª ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 1997, p. 339, aponta o negócio inexistente: "Seria aquele que carecesse de elementos indispensáveis para sua própria configuração como uma figura negocial. Tais elementos são indiscutivelmente dois: a vontade e o objeto. Não se pode conceber a existência de um negócio, conforme temos reiteradamente afirmado, se falta o elemento volitivo. Sem a manifestação da vontade, o negócio não pode formar-se, evidentemente".

Em resumo, inexistente o negócio ante a falta de um elemento essencial para a sua formação, o que é diferente se esse elemento não atendeu os requisitos exigidos para o reconhecimento, importando, então, em nulidade. Se um dos nubentes se faz substituir por outra pessoa, inexistente o casamento, não surtindo qualquer efeito, situação diversa da acarretada pelo desatendimento de algum dos requisitos, como o que trata dos impedimentos ou da idade mínima. (Introdução ao direito e parte geral do código civil – 8. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 621/622). (Negrítei).

A fraude decorreu de fato atribuível à parte ré. Como todo o aparato voltado para a operacionalização do sistema e da segurança é de responsabilidade da casa bancária, não entrevejo possibilidade de se transferir para o cliente o ônus de eventuais falhas. Incumbe ao banco assegurar a inviolabilidade das operações bancárias, de tal sorte a premunir que seus clientes sejam captados por fraudadores, e, como dito, a fraude praticada por terceiro no âmbito de tais operações caracteriza caso fortuito interno. Em uma palavra: houve falha de segurança.

Portanto o serviço foi prestado de forma defeituosa, de vez que não foi oferecida a segurança que o consumidor dele podia esperar, ao que a parte ré responde objetivamente pelos danos daí provenientes, ex vi do disposto no art. 14, caput § 1º, do CDC, e na esteira do que preconiza a Súmula nº 479 do STJ.

Logo, afigura-se imperativa a declaração de inexistência do contrato em tela, com a subsequente restituição dos valores indevidamente descontados.

A repetição se dará na forma simples, e não em dobro – como postulado pelo autor. A fraude foi engendrada por terceiro, utilizando-se do nome da empresa requerida sem o seu conhecimento e autorização, panorama que afasta a violação ao princípio da boa-fé objetiva, exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para que se defira a restituição dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta arbitrária à boa-fé objetiva. (EAREsp. nº 676.608, Corte Especial, rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020).

Os valores serão corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJSP, desde os respectivos pagamentos (Súmula nº 43 do STJ), e sobre eles incidirão juros moratórios de 1% ao mês (arts. 406 do CC e 161, § 1º, do CTN), a partir da citação (art. 405 do CC), admitida a compensação com valores eventualmente liberados pelo réu em favor do autor – desde que comprovado o crédito.

Resta analisar se o ato ilícito acarretou abalo anímico ao demandante.

Ainda que os débitos cobrados não sejam devidos, encarnando ilicitude, o caput do art. 42 do CDC reclama a exposição ao ridículo ou a submissão do consumidor a constrangimento e/ou ameaça – situações sequer aventadas no caso -, e não se encaixam no rótulo de dano moral os transtornos, desconfortos, aborrecimentos ou contratempos pelos quais o homem passa no dia a dia, absolutamente normais na vida de qualquer um e que não têm o condão de atingir o setor extrapatrimonial da esfera

jurídica.

Segundo MARIA CELINA BODIN DE MORAES, quando os atos ilícitos ferem direitos da personalidade, como a liberdade, a honra, a integridade física, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, a própria violação causa dano moral in re ipsa, decorrente de uma presunção hominis. Quando, porém, os efeitos da ação, conquanto não repercutam na órbita do patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo sensações e emoções negativas, pode haver dano moral indenizável se houver prova de sua intensidade em patamar superior ao dos aborrecimentos e dissabores a que todos se sujeitam na vida cotidiana (Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, pp. 157/159).

A despeito dos dissabores experimentados pelo autor em razão das cobranças por contratação fraudulenta, não houve demonstração de nenhum sofrimento anormal que se possa atribuir a esse quadro. Ausente prova de que o transtorno narrado pelo demandante atingiu alto grau de intensidade, a pretensão se limita a contratação indevida, consubstanciando mero contratempo cotidiano, inapto a ecoar negativamente na sua esfera psíquica, a ponto de configurar dano moral indenizável.

Nesse sentido, colho precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo em demandas análogas à presente:

Apelação - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de evidência - Parcial procedência - Empréstimo fraudulento - Inexistência do contrato declarada - Razões recursais que se restringem ao pleito indenizatório - Ocorrência de dano moral não caracterizada - Simples aborrecimento ou transtorno individual e necessidade de ajuizar ação judicial que não gera, por si só, o dever reparatório - Ausência de prova do abalo sofrido - Sentença mantida - Recurso improvido. (Apelação Cível nº 1015444-45.2020.8.26.0361, 14ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 24.06.2021);

APELAÇÃO. Contrato de empréstimo consignado. Averbação de operação de crédito não contratada no INSS. Cancelamento do registro pela instituição financeira. Ausência de prejuízos ou maiores infortúnios à apelante. Circunstâncias do caso concreto que não ensejam o reconhecimento de danos morais. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade. Sentença confirmada. Recurso desprovido. (Apelação Cível nº 1003022-73.2020.8.26.0414, 38ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 22.06.2021); e

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de empréstimo consignado - Ausente prova de prejuízo apto a afetar direito de personalidade da requerente, nem do suposto dano experimentado, quer seja porque seu nome não foi negativado junto aos órgãos de restrição ao crédito, quer seja porque o requerido providenciou o cancelamento do débito antes do efetivo desconto de qualquer parcela no benefício previdenciário da autora, tudo a demonstrar que o ocorrido não lhe trouxe privação em seus proventos - Indevida reparação de ordem moral - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (Apelação Cível nº 1008032-46.2020.8.26.0302, 15ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Mendes Pereira, j. 16.06.2021).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos articulados na inicial para DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 335855497-4, bem como a inexigibilidade dos débitos daí decorrentes, com a subsequente CONDENAÇÃO do banco réu a ressarcir ao demandante os valores indevidamente descontados a esse título, corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJSP, desde os respectivos descontos, e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação; e assim o faço, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Divisada a sucumbência recíproca, mercê do princípio da causalidade, cada parte arcará com metade das despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono do adversário, que fixo, equitativamente, em R\$ 1.200,00, observada a concessão da gratuidade da justiça (arts. 85, §§ 2º, 8º e 14, 86 e 98, § 3º, todos do CPC).

De modo a evitar a oposição de embargos de declaração, ficam preteridas as demais alegações, por incompatibilidade com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado nos limites em que formulado. Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Caso interposto recurso de apelação, abrir-se-á vista à parte contrária para contrarrazões, remetendo-se, incontinenti, ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 1009, §§ 1, 2 e 3, do CPC.

Transitado em julgado e não havendo outras diligências a cumprir, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Piraju, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA